

1500678-69.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500678-69.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500678-69.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "Vitinho", qualificado à fl. 10, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, porque, segundo a denúncia:

"Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta de 04h40min, na Rua Mendes de Moraes, n.º 871, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente-SP, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "Vitinho", qualificado à fl. 10, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em papelotes, pesando aproximadamente 5,09g (cinco gramas e nove centigramas) e, ainda, 14 (catorze) porções de cocaína na forma de "crack", pesando aproximadamente 10,86g (dez gramas e oitenta e seis centigramas), para fins de comercialização, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias de fl. 21/24, laudo pericial de constatação de substância entorpecente de fls. 89/91 e laudo pericial de fls. 89/91. Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado transportou o

entorpecente apreendido até o local, já preparado para imediata comercialização, a fim de aliená-lo a dependentes químicos. Todavia, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Mendes de Moraes, em conhecido como ponto de venda e consumo de substâncias ilícitas nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, quando visualizaram o veículo GM/Monza, placas BQT - 9997, parado no centro da via, de propriedade do denunciado, dialogando em atitude suspeita com Alisson Martim de Oliveira Zanardi, dependente químico, que estava do lado de fora do veículo. Ao notar a presença de policiais, Alisson adentrou o veículo e o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade em direção a cidade de IndianaSP. VICTOR HUGO foi perseguido e na cidade de Indiana abandonou o veículo e rumou em direção ao interior da residência de sua ex-mulher. O denunciado foi abordado e submetido a busca pessoal, não sendo localizado qualquer objeto ilícito em seu poder. Contudo, em revista veicular, os policiais localizaram embaixo do banco do passageiro 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em papelotes, pesando aproximadamente 5,09g (cinco gramas e nove centigramas) e, ainda, 14 (catorze) porções de cocaína na forma de "crack", pesando aproximadamente 10,86g (dez gramas e oitenta e seis centigramas), para fins de comercialização. Ainda, encontraram no banco traseiro do veículo 01 (um) rádio de CD multilaser e 01 (um) rádio CD pioneer, tratando-se de objetos comumente permutados por entorpecentes e sem comprovada origem lícita. Foram localizadas no veículo 02 (duas) facas de cozinha utilizadas no preparo do entorpecente a ser revendido - fls. 89/91. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade de droga apreendida, a forma como cada porção estava dividida e armazenada, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga seria destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes." Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 155/156 e 157/174), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 182), o despacho de fls. 183/187, de 19 de outubro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 251/252), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 256/290), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória quanto a autoria, que no decorrer da instrução mostrou que o réu é usuário de drogas e não traficante, devendo o crime do artigo 33, ser desclassificado para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 25/27; pelo laudo químico toxicológico de fls. 92/94, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0036807) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido, ambos encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 11,67 grama(s) - onze gramas e sessenta e sete centigramas. Massa Líquida: 5,09 grama(s) - cinco gramas e nove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0036808) Descrição: 14 (quatorze) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó, todos encerrando porção de material sólido petrificado. Massa Bruta e/ou

Quantidade: 16,62 grama(s) - dezesseis gramas e sessenta e dois centigramas. Massa Líquida: 10,86 grama(s) - dez gramas e oitenta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo Laudo pericial de objetos de fls. 89/91 que analisou - Item Único (Acondicionado sob o lacre 020498) Descrição: 1 faca, sem marca aparente, constituída por uma lâmina metálica serrilhada cortante presa a um cabo de madeira; 1 faca, da marca "TRAMONTINA", constituída por uma lâmina metálica cortante presa a um cabo de plástico de cor amarela; 1 alicate, da marca "TRAMONTINA"; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Sidnei Aparecido Fabiano de Souza, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pela Rua Mendes de Moraes quando se depararam com o veículo Monza parado no meio da via e o motorista conversava com outra pessoa que estava fora do veículo. Ao perceberem a aproximação da viatura, essa pessoa entrou no veículo e saíram em fuga sendo acompanhado por diversas ruas até atingirem a Rodovia Angelo Renna, e com apoio de outras viaturas, conseguiram fazer a abordagem somente na cidade de Indiana, onde ele desembarcou e saiu correndo adentrando numa residência, ficando homisiado dentro da residência. Em revista no interior do veículo foram localizadas as porções de crack embaixo do banco do passageiro, sendo dado voz de prisão. Indagado, Victor Hugo disse que a droga não era dele. Alisson por sua vez, disse que estava ali para comprar droga do Victor, que não correu, ficando parado dentro do veículo. Quando o Victor parou o veículo, saiu correndo, Alisson ficou dentro do veículo e não resistiu. Quando se aproximaram os dois estavam dentro do veículo. Confirma que fez as buscas dentro do veículo e localizou a droga que estava embaixo do banco do passageiro, onde estava sentado o Alisson, dentro do veículo também foi localizados toca-fitas e toca CDs, que foram apresentados na Delegacia participativa. Victor assumiu a propriedade dos aparelhos. Não tem certeza se havia faca dentro do veículo. Alisson e Victor já são conhecidos nos meios policiais. No local onde foram encontrados é conhecido local frequentado por usuários e traficantes de drogas. Afirma que Victor mora em Presidente Prudente, seus avós moram no Parque Alvorada. No local onde visualizaram o veículo, é comum ver Victor frequentando o local, porém não tinha o abordado antes. Com o Victor nada de ilícito foi encontrado

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

O réu Victor Hugo de Oliveira Santos, em seu interrogatório declarou que possui 20 anos e já foi preso e cumpriu de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que estava naquele local justamente para comprar droga, não tinha dinheiro, mas tinha os aparelhos para trocar por droga. Não conhece ele como traficante, o conhece como Gabriel que chegou correndo dizendo que o traficante não se encontrava naquele momento, mas que ele tinha um pedaço de droga para lhe oferecer. Para não achar que era mentira ou se era verdadeira a droga, pediu um pedacinho para usar, que usou ali mesmo, e quando perceber ele entrou no seu veículo e falou que era a polícia, que iriam pegar a droga, que era para correr, foi então que empreendeu fuga, não por causa da droga, mas porque seu carro estava com a documentação atrasada e ficou com medo de perder o veículo, pois trabalha, recebe de 15 em 15 dias como ajudante de pedreiro, não é registrado. Afirma que as duas facas lhe pertencem, mas que era para trocar o aparelho, que sempre fica trocando o aparelho e nesse dia, utilizou as facas para trocar o aparelho, para revender. Não tinha notas dos aparelhos. Nunca foi condenado por tráfico de drogas. Estava na Rua Mendes, parou o carro, ficou por cerca de 5 minutos quando Alisson apareceu correndo, porque não calcula direito o tempo que ficou ali. Quando parou o veículo, somente o Alisson aproximou-se dele, ele entrou assim que viu a viatura. Não viu ninguém sair correndo naquele momento, somente ele que apareceu no seu veículo, lhe deu um pedacinho de droga para usar, para ver se era verdadeira a droga para comprar, porque os traficante lhe vender droga falsa, passava uma coisa que não era droga, e logo depois que se afastava e parava para usar, porque gosta de usar sozinho, percebia que havia comprado outra coisa e não droga, então por isso que pediu um pedacinho para constatar se realmente era droga, mas a viatura já chegou e não deu tempo de ele pegar o aparelho na mão. Quando a viatura apareceu, ele estava fora do carro e quando percebeu ele entrou correndo no seu carro. Afirma que ele tinha um pequeno pedaço, quebrou um pedacinho e lhe deu para experimentar e quando estava usando a viatura apareceu, não sabe se ele jogou a droga, se ficou com a droga, e não sabe como foi parar droga no seu carro, não tinha droga, foi até aquele local para

comprar, se tivesse droga ali, nem por ali estava, mas longe usando.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, a testemunha Alisson, que não compareceu em Juízo, porém, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, sem qualquer tipo de subterfúgio para tentar ludibriar a Autoridade Policial disse que é usuário de crack e estava na linha férrea quando chegou VITINHO; como já tinha comprado crack dele outras vezes e ninguém tinha mais na linha, VITINHO chegou com seu Monza e parou; foi até o carro para comprar e ele pediu que entrasse no carro; nesse momento, chegou a polícia militar e VITINHO empreendeu fuga, sentido Indiana; VITINHO parou o carro e empreendeu fuga a pé; os policiais conseguiram pegá-lo; dentro do veículo os policiais encontraram algumas pedras de crack e porções de maconha; não vi os aparelho de som; a droga não lhe pertence, como já disse, somente iria comprar crack de VITINHO, portanto, essa narrativa é confirmada pelo policiais Militares que participaram da diligência e corrobora com as demais provas dos autos, para imputar a Victor Hugo, vulgo Vitinho, a propriedade da droga encontrada em seu veículo, além dos objetos que são comumente utilizados por usuário e viciados para trocar por drogas.

Em Juízo, portanto, Victor Hugo, apresentou justificativas, principalmente quanto a propriedade da droga que tenta imputar a testemunha Alisson essa propriedade, além do mais, apresenta versão falaciosa da sua conduta, se confundindo, por vezes, quanto ao momento em que vendia para Alisson, dizendo que teria que experimentar a droga primeira para depois de comprovar se era verdadeira, decidir por compra-la, porém, não encontra amparo na prova dos autos, até porque nenhum pedaço ou resquício de droga foi encontrada, a não ser as porções, já prontas para a venda, dentro do veículo de Victor Hugo.

Percebe-se em seus depoimentos, diversos pontos divergentes, vez que em solo policial disse que ALISSON estava dentro do carro; ALISSON tinha droga com ele; não sei dizer se a droga encontrado no carro era a dele; essa droga não é minha; em Juízo, disse que pegou um pedaço e usou ali mesmo no local, depois Alisson entrou em seu veículo e empreenderam fuga, porém, continuou dizendo que não sabe de quem era a droga.

Ora, se não lhe pertencia, era por certo de Alisson, pois não disse, em momento algum que outra pessoa entrou em seu veículo, mesmo assim, não disse que a droga pertencia a Alisson.

Enquanto que Alisson afirmou que já havia comprado droga de Victor Hugo, conhecido como Vitinho, anteriormente a estes fatos.

Assim, não é crível que estaria ali somente para comprar droga e fugiu da Polícia apenas porque a documentação do seu veículo estava irregular, pois trata-se de versão escapista e fantasiosas, desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (14 porções de crack pesando 12,2 gramas e 2 porções de maconha, pesando 7,01 gramas), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado pela Polícia Militar; não só da droga, mas também dos objetos encontrados dentro do seu veículo, que era utilizado para o transporte e a entrega e distribuição de drogas, ou seja, duas facas e dois aparelhos eletrônicos, sem comprovação da origem lícita, o que por si só, não

denotam o crime de tráfico, mas aliadas a 14 porções de crack, já fracionados e prontas para a venda a terceiros, que pesou cerca de 12,02 gramas, além de duas porções de maconha.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fl. 21, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita dos objetos apreendidos em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa dos réus e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu, em que pese seu Defensor apontar a grave dependência química do réu, comprovando ser apenas usuário, porém, não trouxe aos autos qualquer documentação atinente a gravidade da sua dependência.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para

consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

“Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 – Registro – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

“Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos.” (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Procede, portanto, a ação penal e de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Inicialmente, verifico que a Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão Estadual de Distribuição de Processo de fls. 48/53 e 111/142, mencionadas pelo i.

Representando do Ministério Público em suas alegações finais não podem servir para exasperação da pena base, já que, não há nenhuma informação concreta quanto a condenação a pena de prisão com trânsito em julgado definitiva da decisão.

Outro lado, as certidões de fls. 111/142 são referentes a conduta praticadas pelo réu quando ainda menor de idade, e que também não podem ser levadas em consideração para negar-lhe o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, portanto, atos infracionais não são crimes; atos infracionais, não configuram maus antecedentes tampouco reincidência, não podem ser invocados para prejudicar o réu, assim, não acolho o pedido ministerial para exasperação da pena, justificando que o réu se dedica a atividade criminosa, nem para negar-lhe o benefício do privilégio., até porque, nenhum deles consta a condenação e o trânsito em julgado, o simples extrato do processo ou procedimento juntado, não tem força para indicar os antecedentes por ausência de elementos essenciais do processo.

Nesse sentido foi o recentíssimo julgamento pela. C. 6ª Turma do S.T.J.:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1973540 - SP (2021/0376984-4) EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (4,9 G DE COCAÍNA). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE AFASTAR O REDUTOR, MAS NÃO O FAZ DE FORMA AUTOMÁTICA. HC N. 650.819/SC (SEXTA TURMA, SEÇÃO DO DIA 4/5/2021). JURISPRUDÊNCIA DO STF. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.973.540, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/08/2022.)

Desse modo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054 (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “a existência de inquéritos

policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.

Nessa linha de entendimento, no julgamento do Habeas Corpus n. 151.431 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.5.2018, Segunda Turma), o Ministro Gilmar Mendes sustentou que inquéritos e ações penais em curso tampouco podem servir de fundamento para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin divergiram do relator, mas, pelo empate, a ordem foi concedida, nos termos da seguinte ementa: “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria” (HC n. 151.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2018).

Em 27.11.2018, essa orientação foi firmada pela Segunda Turma, em julgamento unânime: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II – A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.309-AgrR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).

Considerado entendimento assentado pela Segunda Turma do STF no julgamento do Agravo Regimental do Habeas Corpus n. 144.309, não podem inquéritos ou ações penais em curso fundamentar o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por esses argumentos é que não acolho o pedido do Ministério Público em não conceder a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no caso dos autos, posto que o réu embora condenado, não tem na condenação sentença transitada em julgado.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis idem bis.

“Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que

a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]". (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]". (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea do réu em Juízo, conforme preceitua o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

A diminuta quantidade de drogas apreendidos em poder do réu, sendo possível crer que ele não se trata de traficante contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos

de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SANTOS, RG 57761630-4, CPF 47228775805, pai CICERO ANTONIO DA SILVA SANTOS, mãe KATIA CRISTINA CANDIDO DE OLIVEIRA SANTOS, Nascido/Nascida em 15/03/2002, natural de Presidente Prudente - SP, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente; e a pagar a multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

INCONTINENTI, expeça-se alvará de soltura em favor do réu, encaminhando ao presídio em que se encontram recolhidos para o devido cumprimento.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO do veículo apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA